

1. 判决书字号

江苏省镇江市中级人民法院(2023)苏11民终619号民事判决书

2. 案由：借款合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某小贷公司

被告(上诉人):某开发公司、王某某

被告(被上诉人):某建设公司、某混凝土公司、某装饰公司、章某某

被告:刘某、张某甲、唐某、张某乙

【基本案情】

2017年4月18日,某小贷公司与某建设公司签订了《借款合同》,约定借款种类为短期借款;借款金额300万元;月利率8.7%等内容。同日,某小贷公司与某混凝土公司、某开发公司、某装饰公司、王某某、章某某签订《保证合同》,约定为《借款合同》项下债权提供连带责任保证。当日,刘某、张某甲、唐某、张某乙向某小贷公司出具《承诺书》,以家庭财产承诺对某建设公司的借款承担无限连带清偿责任。某小贷公司依约向某建设公司发放借款300万元。某小贷公司出示了2017年4月某混凝土公司、某开发公司、某装饰公司分别作出的《董事会(股东会)决议》,均载明:三公司经董事会(股东会)研究决定,同意为上述借款提供连带责任保证。

合同约定的借款期限届满后,某建设公司未能按约还款,某建设公司分别于2017年4月18日、2018年10月18日、2019年4月18日三次向某小贷公司提交《借款人展期申请书》。上述三份《借款人展期申请书》有保证人盖章、签字。

某小贷公司提交的《承诺书》载明:“某小贷公司:2017年4月18日刘某在贵公司贷款300万元;2017年4月18日某建设公司在贵公司贷款300万元;2017年6月9日张某某在贵公司贷款210

万元，上述贷款均已逾期，未依约归还(仅归还部分，具体以还款凭证为准)，承诺人作为上述贷款的保证担保人，同意继续承担连带保证责任。”落款“承诺人1”处加盖有某装饰公司公章，同时有“章某某”签名，日期为2021年12月19日；“承诺人2”处有“章某某”签名。《承诺书》右下方有“已还贰佰万元正”手写内容，此处文字下方有某安装工程公司公章，并有“王某某”签名，日期为2021年12月21

日。《承诺书》右下方有“刘某”签名，日期为2021年12月21日。

某小贷公司提交的另一份落款日期为2022年1月5日的《承诺书》载明内容与上述承诺书一致。落款“承诺人1”处加盖有某混凝土公司公章，同时有“刘某”签名；下方还有一处“刘某”签名。

某混凝土公司企业类型为有限责任公司(自然人独资)，股东为刘某，持股比例100%。某开发公司有两名股东分别为某安装工程公司(持股62.5%)，王某某(持股37.5%)。某开发公司和某安装工程公司的法定代表人均为王某某。某装饰公司有两名股东，章某某持股比例51.8698%，另一股东持股比例48.1302%。

【案件焦点】

1. 同一份继续承担保证承诺书上，若法定代表人仅在公司盖章处签字，未以个人身份签字，法定代表人个人是否承担保证责任；2. 若法定代表人仅代表公司作出担保意思表示，能否推定其以股东身份同意公司对外进行担保，进而判断公司股东同意担保的比例符合法律规定的三分之二，判令公司承担全部担保责任。

【法院裁判要旨】

江苏省镇江市京口区人民法院经审理认为：案涉合同及承诺书系当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规效力性强制规定，合法、有效，合同各方均应按照约定全面履行各自的义务。某建设公司未按借款合同约定履行还款义务，已构成违约。某小贷公司主张借款期限内的利息及复利，分别按月利率8.7%计算，两者之和未超过相关规定，予以支持；某小贷公司主张借款期限届满后的罚息及复利，分别按月利率13.05%，两者之和超出了年利率24%的标准，对于超出部分，不予支持。某小贷公司主张某建设公司承担保全保险服务费于法无据，不予支持。

江苏省镇江市京口区人民法院判决：

一、某建设公司于判决发生法律效力之日起七日内归还某小贷公司300万元并支付利息、罚息及复利；

二、某混凝土公司、某开发公司、王某某、章某某、刘某对某建设公司上述第一项给付义务承担连带清偿责任；

三、某装饰公司对某建设公司上述第一项判决确定的债务不能清偿部分承担二分之一的赔偿责任；

四、驳回某小贷公司其他诉讼请求。

宣判后，某开发公司、王某某不服提起上诉。

江苏省镇江市中级人民法院经审理认为：案涉《承诺书》内容不违反法律、行政法规效力性强制规定，合法有效。《承诺书》明确载明“承诺人作为上述贷款的保证担保人，同意继续承担连带保证担保责任”，案涉借款的保证人在保证期间届满后，自愿在《承诺书》上签字盖章，系承诺人向债权人某小贷公司作出新的保证。

关于王某某在《承诺书》上签字行为的认定，应当符合当事人的真实意思。从案涉两张《承诺书》显示的内容来看，某装饰公司公章处的“章某某”签字和某混凝土公司公章处的“刘某”签字均是代表两公司的法定代表人。王某某系某安装工程公司的法定代表人，其在某安装工程公司公章处签字，应认定其作为该公司法定代表人签字。王某某未在《承诺书》上单独以个人名义签字，一审法院认定王某某应继续承担保证责任，有失妥当。

关于某安装工程公司在《承诺书》盖章并注明“已还贰佰万元正”行为的认定。某安装工程公司持有某开发公司62.5%的股权，在某开发公司出具的《董事会(股东会)决议》上，某安装工程公司亦加盖公章，表明某安装工程公司明知某开发公司为案涉借款提供保证担保。某安装工程公司曾向某小贷公司支付200万元，因某开发公司是承诺书载明三笔借款的保证人，应认定某安装工程公司系代某开发公司履行保证责任。某安装工程公司在《承诺书》上盖章并写明已还款数额，表明某开发公司有继续承担保证责任的意思表示。因王某某未以个人名义作为股东签字，某安装工程公司所持某开发公司股权比例未达三分之二，一审法院以担保合同系由单独或者共同持有公司三分之二以上有表决权的股东签字同意无须股东会决议，判令某开发公司承担全部保证责任，

存在不当之处。某小贷公司作为债权人，某开发公司作为担保人对《承诺书》中仅有某安装工程公司盖章导致担保无效，均存在过错。根据法律规定某开发公司应对某建设公司不能向某小贷公司清偿部分借款的二分之一承担赔偿责任。

江苏省镇江市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：改判某开发公司对某建设公司第一项判决确定的债务不能清偿部分承担二分之一的赔偿责任，王某某不承担保证责任，维持一审法院的其他判项。

【法官后语】

在金融借款合同中，中小微企业作为借款人，通常会被要求提供诸多的保证担保，以确保金融机构或小贷公司债权的实现。企业之间的互相提供保证担保是常见现象，大多数企业的法定代表人亦会被要求以个人名义提供保证。由于经济形势不景气，许多贷款无法按约归还，为了缓解借款人的压力和降低不良贷款率，金融机构允许借款企业多次展期，并要求各保证人继续承担保证责任。在判断保证人是否具有继续担保的真实意思表示时，需要有明确的证据，不能推定其具有担保意思表示。尤其是在法定代表人仅代表所属公司签字时，不能当然推定其亦同意作为个人继续承担保证责任，但其除代表公司法定代表人之外，又以个人身份签字的情形除外。

法定代表人在法律概念上是代表法人进行民事活动的代表人，客观上必须由个人来代表法人作出法律行为，势必会涉及法定代表人履行职务行为与个人行为的区别。司法实践中，一些法人直接以公章对外代表公司作出意思表示，有的则是以法定代表人签字代表公司行为，更多的是以公章加法定代表人签字的方式作出法人的法律行为。当法定代表人所代表的法人与其个人均存在某个意思表示的表象时，如何区分该法定代表人签字行为是职务行为还是个人行为，对法定代表人的个人合法权益会产生重大影响，司法审查需审慎处理。

一、法定代表人履行职务行为的认定

由于法定代表人既是法人的代表人又是自然人的双重身份特征，其从事的民事活动，既可以代表法人意志，也可能是其个人的意思表示。如果法定代表

人以法人名义从事民事行为，其法律后果由法人负担。通常情况下，法定代表人对外代表法人从事相关行为需以法人公章或其他授权手续作为表象，如果仅有法定代表人个人行为，没有法人其他文件相互印证，通常应理解为个人行为。司法实践中判断法定代表人的行为性质，往往会遇到法定代表人签字单独出现或与法人公章同时出现的不同情形，此时必须结合具体情况区别认定职务行为或个人行为。

（一）仅有法定代表人签字没有法人公章

1. 个人的意思表示。法定代表人首先是作为自然人而存在，不能因为其还是某法人的代表人，就否定其自然人的属性。作为独立民事主体，法定代表人所作的个人意思表示及行为后果由其个人承担，与法人无涉。比如，法定代表人在借条上签字借款用于家庭生活，与其所在的法人单位没有任何牵连，此时借款人系法定代表人个人。

2. 明示为法人意思表示。法定代表人虽然第一属性是其自然人身份，但是其还兼具法人机关的特定社会身份。倘若法定代表人在从事民事行为中明示其代表人身份或者有证据证明其签字为履职行为，则根据法定代表人的实质内涵范围，因法定代表人与法人是同一人格主体，其法律行为后果由法人承担。比如，法定代表人在借条上签字借款，借条明确载明款项用于法人单位的某项目，相对人基于对其法定代表人身份的信任，有理由相信借款人系法人，此时法定代表人的签字行为的法律后果由法人承担。

3. 名不符实的意思表示。法定代表人签字而没有公章印章情形下，在有证据证明行为系法人而为时也应当由法人承担相应法律后果。比如，虽然借条上没有写明借款用途，法定代表人签字确认，但事实上借款用于法人的具体事务或项目上，法定代表人主张系职务行为符合实际情况时，应当由法人承担还款义务。

（二）既有法人印章又有法定代表人签字

在“章人合一”时，法定代表人系代表法人履行职务行为应当顺理成章，此时不应当直接将法定代表人签字行为扩大至个人亦有该意思表示。如果有证

据能够证明法人通常对外意思表示以公章为准，不需要法定代表人再签字确认，而法定代表人签字有惯例证明系代表个人行为，也可以认定个人意思表示，但必须要谨慎，以免突破法定代表人作为个人的意思表示及责任范围。

本案中之所以改判王某某不承担保证责任，也是根据具体案情的审慎判断。因案涉三个公司均为保证人，该三公司的法定代表人亦是保证人，在此前的保证合同中均能证实。在继续保证承诺书中，其中两个公司的法定代表人均两次签字，一次签字系在公章处，另一处签字是单独签字，能够明确区分是代表法人和个人。但是，王某某作为某公司的法定代表人，亦曾是以个人名义担保的保证人，其仅在公章处作为法定代表人签字，并未作为个人再次在承诺书上签字。此时如果不加判断地认为，王某某个人也作出了继续担保的意思表示，显然不符合其真实意思，也有悖其签字的表现形式。如果王某某有继续担保的真实意思表示，其应当像其他两人一样再次单独以个人名义签字，但其并没有签第二个名字，故不应当让王某某承担继续担保的责任。

二、法定代表人越权担保的认定及处理

如前文所述，法定代表人无权代表法人直接作出对外担保的意思表示，需要有法人权力机构的决议作为授权依据。但基于司法实践的复杂性，《全国法院民商事审判工作会议纪要》规定了例外情形，即四种情况下即便债权人知道或者应当知道没有公司机关决议，也应当认定担保合同符合公司的真实意思表示。只要债权人有证据证明法定代表人以公司名义签订担保合同符合公司真实意思，该担保行为就符合民事法律行为有效要件。

（一）法定代表人与个人行为的区别

法定代表人签字可以代表法人，也可以代表个人，能否同时代表法人和其个人？这个问题可能在不同案情下会有不同的答案，需要根据法定代表人代表行为的表现形式判断。如果一个法人通常对外以公章即可代表其意思表示，则法定代表人不需要签字确认，法定代表人即便签字确认也可能是对法人行为的再次确认，也可以是代表其本人作出同样的意思表示。一般情况下，如果法定代表人签字同时加盖公章，法定代表人签字会落在公章处，即签字与公章在同

一位置叠加，是履行职务的签字行为。

本案中某开发公司在保证合同落款的保证人处加盖公章，王某某在公章处签字仅是履行法定代表人的职务行为。因为王某某作为个人保证人，在另一份保证合同中单独以个人名义签字，系代表其个人进行担保的意思表示。从上述两份保证合同签订情况来看，王某某在公章同一位置处签字系代表法人，并不代表其个人。

在案涉保证期限届满后，各保证人又在继续保证的承诺书上签字盖章，能够表明各保证人自愿对超过保证期间的同一笔借款继续承担保证责任。此时，两份继续保证的承诺书中的落款签字仍然可以看出，法定代表人在公章处签字，愿意继续保证的法定代表人个人也以第二次签字形式表达其个人意思表示。但此时王某某并没有进行第二次签字，仅在公章处签字，应当认定其并未以个人名义作出继续保证的承诺，债权人无权要求王某某承担继续保证责任。虽然王某某在案涉借款的第一次保证合同中明确作为个人保证人，因首次保证期限早已经过，其个人的保证责任已经消灭。

（二）法定代表人行为与股东行为的区别

厘清了法定代表人和个人行为应区别认定的意义，还应注意到，法定代表人通常还有一个身份——法人的股东。股东可以是自然人也可以法人，一个自然人股东的法律行为只能以个人行为来表示，当一个法定代表人同时是法人的股东时，亦应当区分法定代表人和股东的行为性质。目前，我国的法定代表人一定是自然人，如果这个自然人的行为被认定为法定代表人的职务行为，则其行为通常不能同时代表其个人，亦不能将法定代表人签字认定为股东的意思表示。基于防范风险的考虑，法人是担保人时，如果法定代表人作为自然人也同意担保，应当可以理解法定代表人作为股东也同意公司对外担保。由于法定代表人的特殊身份，其作为公司意思表示机关时，只能代表公司，不能推定其个人和作为股东也具有相同意思表示。但作为法定代表人作为个人所作法律行为，通常可以解释为法定代表人作为股东也具有该意思表示。当然上述原则均是一般性理解，如果个案存在特殊情况，应当具体问题具体分析，最好能够将法定

代表人、个人和股东三者的行为加以区分。

公司对外担保需经公司机关决议例外中第四种情形是“担保合同系由单独或者共同持有公司三分之二以上有表决权的股东签字同意”，应当理解为因满足了公司决议的实质要件，有三分之二以上表决权的股东同意对外担保，即代表了公司决议机关的真实意思。此时是否需要公司加盖公章，再由有三分之二以上表决权的各股东签字或盖章呢？笔者认为，加盖公司公章的表现形式是为了确保公司的真实意思表示，既然有三分之二表决权股东的表决结果（签字或盖章），已经足以确认公司作出了对外担保的真实意思表示，是否加盖公司公章已经没有法律意义。

本案当事人关系较为复杂，案涉保证合同中原保证人是某开发公司，某开发公司虽没有盖章但某安装工程公司盖章确认，其盖章行为应认定为作为某开发公司的股东所作承诺。本案王某某具有多重身份，一是某开发公司的法定代表人，二是某开发公司持股37.5%的股东，三是某安装工程公司的法定代表人，某安装工程公司又是某开发公司持股67.5%的股东。王某某在承诺书上的签字只是代表某安装工程公司，不能认定为个人行为，也不能认定其以股东身份作出了继续承诺的意思表示。本案承诺书中某安装工程公司的盖章和王某某的签字，只能认定为某安装工程公司作出了继续保证的意思表示，因某安装工程公司占某开发公司股份的62.5%，未达到三分之二，故某开发公司对案涉借款继续保证的承诺为无效。

（三）担保无效时法人的赔偿责任

当担保合同无效时，并非不产生任何法律后果。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第十七条规定，债权人与担保人均有过错的，担保人承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。法定代表人越权担保导致担保合同无效，如果符合上述规定，担保人亦需要承担赔偿责任，此时法定代表人是代表法人所作意思表示，应由法人承担赔偿责任。但有观点认为，法定代表人越权担保类推适用《中华人民共和国民法典》第一百七十一条的无权代理规则，对于法定代表人越权担保的情

形，未经公司追认，如果以缔约过失责任为相对人提供救济，则承担赔偿责任的主体应为法定代表人，而非公司。该观点虽有一定法理基础，但并未被司法实践所接受，法定代表人承担赔偿责任的司法案例并不多见。笔者认为法定代表人越权代表对外的责任主体仍是公司，而非法定代表人个人，如果公司认为法定代表人有过错，可以向法定代表人追偿。

本案中，王某某是某开发公司和某安装工程公司的法定代表人，其签字行为系履行职务行为。如果王某某系代表某开发公司签字，因该公司没有正式股东会决议亦不符合无须决议的例外情形，其显然属于越权代表，担保合同无效。因债权人和担保人并非签订首次保证合同，且双方系法人主体应明知公司对外担保的规范要求。但在继续承担保证承诺签订时，债权人未尽到审查义务，担保人利用两个关联公司的关系，未规范作出担保的意思表示，均存在过错，担保人即某开发公司应承担债务人不能清偿部分的二分之一的赔偿责任。

编写人：江苏省镇江市中级人民法院 李珍珠

公司作为连带保证人时，其股东出资义务可否加速到期

—— 谭某某诉刘某甲等民间借贷案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

重庆市第五中级人民法院(2024)渝05民终1532号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):谭某某

被告(上诉人):刘某丙、刘某乙、徐某某

被告：刘某甲、钟某某、梅某某、某文化公司、某互联网公司、某科技公司、陈某

【基本案情】

2019年至2020年，刘某甲多次向谭某某借款，后双方于2020年12月5日就借款进行结算，形成《欠条》一份，载明：刘某甲共计欠谭某某人民币9750000元，从2019年1月15日起按欠款金额的年化利率36%计算利息，截至2020年5月20日利息已支付，2020年5月20日后未再支付任何利息，还款期限为2020年12月31日前。某互联网公司等确认为前述债务承担连带责任保证担保。

某互联网公司的股东为钟某某，认缴出资80万元，持股80%，陈某认缴出资20万元，持股20%，认缴出资时间均为2038年12月31日，钟某某为法定代表人。该公司被重庆市渝北区人民法院列为失信被执行人，有终本案件3件，未履行标的41697元。

因刘某甲未按时偿还借款，谭某某诉至法院，请求判决：1. 刘某甲偿还借款本金9750000元及利息；2. 某互联网公司对刘某甲的上述全部债务承担连带保证责任；3. 钟某某、陈某对某互联网公司的债务，在其未出资的范围内承担补充赔偿责任。

【案件焦点】

公司作为连带保证人不能清偿债务时，其股东认缴出资未到期的情况应否加速到期。

【法院裁判要旨】

重庆市南岸区人民法院经审理认为：谭某某举示了相应银行交易流水，与其2020年12月5日与刘某甲对账签署《欠条》载明金额可以印证，足以证实原、被告之间的借贷真实发生，借款合同合法有效，刘某甲应当承担偿还借款本息的责任。

钟某某为某互联网公司的法定代表人，持有该公司股权80%, 其在欠条上

担保人处签章，无须再由公司决议机构进行决议，某互联网公司依法应对刘某甲的债务承担连带清偿责任。某互联网公司均在重庆市渝北区人民法院被列为失信被执行人，且存在终本执行案件，应当认定其缺乏清偿能力，具备了破产原因。为保护债权人利益，未届出资期限的股东在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任。为此，钟某某、陈某作为被告某互联网公司的股东，应当在其未出资范围内对该公司在本案中的债务承担补充赔偿责任。

重庆市南岸区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十三条之规定，判决如下：

一、被告刘某甲于本判决生效之日起十日内偿还原告谭某某剩余全部借款本金9750000元及支付借款利息；

二、被告某互联网公司等对被告刘某甲的上述全部债务承担连带清偿责任；

三、被告钟某某、陈某作为被告某互联网公司的股东，在其未出资范围内对被告某互联网公司在本案中的债务承担补充赔偿责任；

四、驳回原告谭某某的其他诉讼请求。

一审宣判后，双方均提起上诉。后重庆市第五中级人民法院作出(2024)渝05民终1532号民事判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

2023年修订的《中华人民共和国公司法》，首次在法律层面确定了注册资本认缴制，股东据此享有期限利益，债权人不能以公司不能清偿到期债务为由，请求未届出资期限的股东在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任。此后，《全国法院民商事审判工作会议纪要》（以下简称《九民纪要》）在坚持该出资基本原则的同时，规定了两种除外情形，其中之一就是在公司作为被执行人的案件中，如人民法院已穷尽执行措施仍无财产可供执行，已经具备破产原因，但不申请破产的，股东不再享有出资期限利益，不能再以出资期限未届拒绝履行其在公司成立之初就许诺认缴的出资金额。结合上述司法规范

性文件的表述可知，该条适用的要件事实之一就是公司处于债务人的地位，且已成为被执行人。此处的“债务人”是否仅限于与债权人对应的债务人，保证人等能否也可作为广义上的“债务人”纳入其中，并适用上述规定。换言之，在连带保证人被穷尽执行措施后无财产可供执行，但尚未穷尽主债务人财产执行措施的情况下，债权人能否主张已被穷尽执行措施的连带保证人的股东出资加速到期，司法实践中争议较大。

一、司法裁判的观点分歧

通过梳理现已公布的部分裁判文书、典型案例等，司法裁判的主要观点分为两种：一种意见认为，债权人不能直接向连带保证人的股东主张出资加速到期。首先，保证债务为或有债务、从债务，主债务人才是债务的最终承担者，对主债务人强制执行后，债权尚有可能被清偿，保证债务并不必然存在，因此不能直接要求保证人的股东出资加速到期。其次，股东出资加速到期是一种补充赔偿责任。补充责任的定位表明债务的承担存在顺序，公司处于第一顺位，未出资股东处于第二顺位。在公司为他人提供连带保证的情况下，公司与主债务人应同为债务的第一顺位责任人，公司股东的未缴出资应处于第二顺位。债权人只有在第一顺位的债务人不能清偿其债务时，才能就不能清偿的部分向未出资股东主张赔偿。最后，保证人承担保证责任后，还可以向债务人追偿，但股东出资期限利益的损害是不可逆的。当主债务人的清偿情况仍不明朗时，仅因不确定的清偿状态而牺牲股东出资的期限利益，会导致法益保护的比例失衡。另一种意见认为，债权人可以主张连带保证人的股东出资加速到期。根据《九民纪要》第六条规定，股东出资加速到期的关键是公司是否已经实质性满足破产条件，只要公司作为被执行人，已具备破产原因而未申请破产，债权人即有权要求股东出资加速到期。在既有主债务人又有保证债务人的情况下，债权人有权自行选择实现债权的方式和路径，主债务人与连带保证人之间的追偿权系其内部之间的清算关系，不影响债权人向连带保证人求偿。因此，在已对连带保证人穷尽执行措施而仍未获偿的情况下，该保证人实质上已具备破产原因，故债权人可以主张该保证人的股东出资加速到期。

二、连带保证人股东出资加速到期的理论支撑

(一) 连带责任保证人与债务人并无担责先后顺序、比例限制

连带责任是指依照法律规定或者当事人的约定，由两名及其以上的责任人对权利人承担全部民事责任的责任类型。承担责任的每一个主体均负有向权利人清偿全部债务的义务，并无先后顺序，也无大小、比例限制。连带责任保证作为连带责任的一种类型，则是保证人通过保证人合同、承诺书等意思表示的载体，展现出与债务人对债权人一并清偿债务的保证类型。此情形下，一旦债务人在合同约定或法律规定的期限内未履行完毕合同义务，则债权人既可要求债务人向其清偿债务，也可要求保证人清偿债务，还可同时向债务人、保证人同时主张权利，债权人享有自主选择责任主体的权利。此时，连带责任保证人的地位更类似于债务人，只是身份标识与债务人不同而已，其无权对抗债权人享有的担责主体的选择权。反观一般保证或者其他承担补充或填补责任的主体，与狭义层面的债务人并非平行站位于债权人面前，而是劣后于债务人的身位之后，只有在债务人经过强制执行后仍无法完全清偿债务时，方可触发其承担责任的绳索，启动剩余未清偿债务的偿还程序。

(二) 股东通过出资代偿的法律效果归属于公司

根据《中华人民共和国公司法》第十五条的规定，有限责任公司对外为其他主体提供担保之时，如系非关联担保，需经股东会或董事会决议。此时参加股东会或董事会的成员多为股东本人或其间接指派选任的董事，作出担保的决议也是股东或董事经过深思熟虑的结果。无论是股东会决议，还是董事会决议，均直接或间接代表了股东的意志。作为公司经营资产重要来源的股东出资情况，股东及董事更是心知肚明。因此，在公司作出对外担保的决议之时，股东或董事应当预见到将来所要面临承担责任的风险，尤其是在公司资产状况恶化难以为继、出现了资不抵债的破产情形时，这些风险都属于股东能够预判的范围之内。如果再对股东的出资期限利益进行无遮拦、无底线的保护，将会严重危及债权人的债权利益。退一步讲，如果股东会或董事会作出连带担保决议之时，股东未出资，无法启动其出资加速到期机制，则会出现股东在公司没有资产时或之后流失了资

产时，其可借“有限责任”之名躲在公司背后依然逍遥自在，这将会导致公司担保功能的严重弱化甚至虚化。另需指出的是，股东在其出资限额范围内向债权人清偿债务之时，其名下的资产实际已转化为公司的资产，完成了本应承担的出资义务，只是无须再将拟出资的资产转入公司账户内或登记在公司名下，再由公司向债权人清偿的既定程序，而是采取了由股东直接向公司的债权人清偿的方式，避免了中间无谓、烦琐的交割环节。通过此种模式，债权人与保证人、保证人与其股东之间的债权债务关系合并进行了处理。因此，股东清偿的债权额度就是公司作为保证人清偿的额度，清偿后的法律效果实际归属于公司，公司可基于此再向债权人追偿。

三、新公司法关于股东出资期限利益的指引导向

虽然股东期限利益在一定程度上优化了投资经营环境、激发了市场活力，但与此相伴生的却可能是公司注册资本的空心化，这在一定程度上动摇了公司资本充实原则，削弱了商事交易的安全性。结合公司法历年来修订或修正的脉络、精神可知，从2013年初次规定无任何限制的股东出资利益，到《九民会议纪要》增加了两种非破产情况下可加速到期的情形，再到新公司法，立法层面对股东出资期限利益的保护力度有逐渐降低之势，一开始仅限于公司处于破产状态方可破除，而现在只需公司不能清偿到期债务时就应加速出资到期。由此可知，当公司外部的债权人权益处在清偿不能的危境中时，股东的出资期限利益被动压缩回退，让位于债权人的权益保障。为此，司法裁决之时，应当结合新公司法的规定，明确股东期限利益的保护边界，把控好与债权人利益碰撞之时的取舍方向，才能不断地为经济环境提供市场化、法治化的规则指引，正确精准地发挥司法的价值引领作用。

编写人：重庆市南岸区人民法院 林颖 李明刚

主合同无效导致保证合同无效时保证人过错的认定及责任承担

—— 丁某诉郑某甲等民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省宁波市北仑区人民法院(2023)浙0206民初1541号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：丁某

被告：郑某甲、郑某乙、景某某

第三人：沈某某、钟某某

【基本案情】

2021年4月，被告郑某甲经人介绍向第三人沈某某借款200万元，沈某某要求必须提供担保。后其中50万元以郑某甲一套房子签订协议提供担保，150万元由郑某甲联系保证人郑某乙、景某某提供担保。涉案《担保借款合同》系沈某某提供的格式合同，郑某乙、景某某在合同首页保证人处签字按印并填写了身份信息，并在合同最后一页担保方处签字按印。郑某甲在合同首页借款人处及最后一页收条的收款人、乙方处签字按印。之后由丁某实际出资并在合同首页的出借人处和最后一页的甲方处签字按印。合同借款金额处填写了150万元，合同对借款利率、还款方式、归还期限等没有明确约定。2021年4月23日，丁某向郑某甲

转账150万元，同日钟某某向郑某甲转账50万元。上述期间，丁某与沈某某、钟某某一起做短期资金周转生意。

2021年5月7日，沈某某向钟某某转账30万元用以归还钟某某出借给郑某甲的款项，同年6月，郑某甲按照沈某某的指示向钟某某转账24万元。2021年5月至7月，郑某甲四次向沈某某转账共计24万元。同年8月，案外人向沈某某转账12万元，沈某某认可该款系涉案200万元借款的还款。综上，郑某甲还款金额共计60万元。后丁某诉请郑某甲归还借款本金150万元并支付相应利息、支付律师费12.5万元，并由郑某乙、景某某承担连带责任。本案审理期间，沈某某将郑某甲转给其的6万元缴纳至法院，钟某某将郑某甲转给其的4万元（扣除本金50万元）缴纳至法院，均表示愿将该款抵作郑某甲偿还丁某的款项。

根据丁某的银行账户2021年4月21日贷款结息扣收利息情况显示，其间丁某尚有200余万元的银行贷款未偿还，其银行账户流水明细中显示与沈某某、钟某某等人之间的资金往来金额大、频率高。案涉款项150万元绝大部分来源于王某某和叶某某，该二人与丁某之间资金往来频繁（叶某某系丁某配偶）。

【案件焦点】

保证人郑某乙、景某某是否存在过错及责任的承担。

【法院裁判要旨】

浙江省宁波市北仑区人民法院经审理认为：保证合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效的，保证合同无效。保证合同被确认无效后，债务人、保证人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。主合同无效导致第三人提供的保证合同无效，保证人无过错的，不承担赔偿责任；保证人有过错的，其承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的三分之一。本案中，保证人郑某乙、景某某分别为郑某甲的母亲和朋友，其在明知郑某甲负债累累的情况下，轻易在出借人及借款金额均为空白的借款合同上签字担保，对主合同未尽审查义务，其行为对涉案借款合同的成立起到了促成作用，具有过错，但其过错相对出借人和借款人较小，故法院酌情判定保证人郑某乙、景某某承担郑某甲不能清偿部分债务四分之一的赔偿责任，其向原告承担赔偿责任后，可以向郑某甲追偿。

浙江省宁波市北仑区人民法院判决如下：

一、被告郑某甲应于本判决发生法律效力之日起七日内返还原告丁某借款本金150万元，并支付该款自2021年11月4日起至实际清偿之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算的利息损失；

二、被告郑某乙、景某某对被告郑某甲不能清偿部分债务承担四分之一的赔偿责任，郑某乙、景某某在承担赔偿责任后，有权向郑某甲追偿；

三、驳回原告丁某的其他诉讼请求。

原、被告均未上诉，案件已生效。

【法官后语】

保证合同是所涉主债权债务合同的从合同，具有从属性，当主债权债务合同无效时，作为从合同的保证合同亦属无效，但并不必然导致保证人无须承担责任。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第十七条规定，主合同无效导致第三人提供的保证合同无效的，应当区分两种情形确定保证人的赔偿责任，一种是保证人并无过错，此种情形下保证人无须承担赔偿责任；另一种是保证人具有过错，此时保证人需要承担赔偿责任，但所承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的三分之一。本案即涉及其中保证合同随主债权债务合同被认定无效后，保证人责任应如何承担的法律适用问题，如何在审判中准确把握保证人过错的认定及责任的承担相关认定标准，是本案中值得研究探讨的重点问题。

一、主合同无效时保证人过错的责任定性

主合同无效导致保证合同无效时，保证人过错责任的性质历来存有争议。一种意见认为，保证人违反对无效事由的注意义务，侵犯了债权人的债权，属于侵权责任范畴；另一种意见则认为，保证人的过错属于缔约过失责任，这种缔约过失责任不是主合同的缔约过失责任，而是保证合同无效的缔约过失，是主合同无效的过错向保证人的延伸。因为保证合同的目的与作用在于保障债权的安全与实现，其本身并不增加交易价值，只是增加交易安全。而且在主合同无效的情况下，债务人对债权人所应当承担的民事责任也是缔约过失责任的范

畴，债务人有过错时，对债权人所应当承担的赔偿责任也是信赖利益损失，而不是履行利益的损失，所以保证合同因主合同无效而无效且保证人有过错时，其所应当承担的赔偿责任的计算基础应是主债务人应当向债权人承担的民事责任，包括返还财产以及赔偿信赖利益损失的民事责任，保证人只有在存在过错的前提下才需承担该责任。实践中，第二种意见成为主流，即过错保证人的行为实际促使了无效的主合同的存在，侵害了主合同中债权人的信赖利益，对保证合同的无效有过错，与缔约过失责任具有同质性。

二、主合同无效时保证人过错的认定

保证人过错责任既为缔约过失责任，则参照《中华人民共和国民法典》第五百条缔约过失责任的规定及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第十七条第二款的规定，对保证人过错责任的判断，应当结合保证人在主合同订立时的作用、保证人主观认识与客观行为的关联等方面加以综合认定。

（一）保证人在主合同订立时的作用

1. 明知或应知主合同无效仍然提供担保

保证人的过错不是指保证人在主合同无效上的过错，而主要体现在明知或应当知道主合同无效仍然提供担保。实务中对于主合同无效事由的审查至关重要，如在主合同订立之时或主合同订立之后，借款发放之前，保证人参与主合同订立或充任中间人促成主合同签订时，应认定保证人明知主合同无效；如保证人在主合同订立过程中故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，提供虚假信息或有其他违背诚实信用原则的行为，也应当认定为明知主合同无效；如保证人未直接参与主合同的订立，当主合同因违反法律、行政法规的强制性规定或违背公序良俗原则而无效时，应结合保证人的经验、职业、专业知识等综合判断其对主合同无效是否明知。

2. 保证人未尽审查义务

保证人在订立合同时是否对主合同已尽必要的审查义务也是需要考量的因素之一。具体而言，在无法证明保证人直接参与主合同的订立或充当居间人员

等情况下，要从保证合同订立时保证人是否履行注意义务对主合同效力审慎审查，如保证合同订立的时间是否早于主合同的订立，保证合同的内容是否脱离于主合同，进而判断保证人在其中有无过错。

3. 保证人促成无效主合同签订

保证合同是典型的风险合同，多数情况下债权人是基于保证人的担保才愿意与债务人缔结合同，一旦债权人知晓主合同效力存在瑕疵，则通常不会缔约或者要求债务人及时补救。然而，为了促成主合同成立，保证人还可能积极以提供担保为由促成缔约，进而使债权人蒙受损失。因此，保证人的过错还体现在通过提供担保诱使无效的主合同成立，该种情况下保证人的过错较前者更大。

(二) 保证人主观认识与客观行为的关联

主合同无效后果的产生有多种原因，评价保证人在主合同订立中的过错，除要考察保证人提供担保的动机和目的外，还要考察保证人与债权人、债务人之间的利益关联。如果保证人对于其所担保的交易享有商业利益时，保证人应具有更高的审查义务，如果保证人仅出于情谊而为亲友无偿提供担保的，则其审查义务相对较低。如果保证人对提供担保的行为缺乏明晰的主观认识，则难以判定其是否具有主观过错，若保证人与债务人之间频繁“搭档”配合缔约的，则其主观认识与客观行为之间的利益关联则十分明显。如本案中，法院认为保证人郑某乙、景某某存在过错，主要原因在于：首先，被告郑某甲系郑某乙儿子，其与景某某又系朋友关系，郑某乙、景某某对当时郑某甲有较多外债、经济状况较差明知，其自甘承担较大的担保风险；其次，郑某乙、景某某先后在出借人及借款金额均为空白的借款合同上签字担保，对于主合同是否有效持放任态度，未尽审查义务；最后，郑某甲向他人借款时，债权人明确要求必须提供两名以上的保证人才愿意出借，在此情况下郑某甲联系郑某乙及景某某提供担保，最终促成借贷合同的签订及款项出借，在此情况下，实际是保证人的行为促成了主合同成立，进而衍生了主合同无效的法律后果。

三、过错保证人的责任承担范围

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》

第十七条第二款的规定是基于，保证合同无效是因为主合同无效导致，在保证人存在过错的情况下，主合同当事人原则上也有过错，均有对主合同效力进行审慎审查之义务，对于债权人的损失，应当以债权人、债务人、保证人三方均分承担为标准，因此保证人对于债权人的损失赔偿责任应限定在债务人不能清偿部分的三分之一以内。在具体适用中，保证人有过错的，保证人承担民事责任的部分不应超过债务人不能清偿部分的三分之一，此即确认了该情况下保证责任承担的上限。至于在个案中，还应结合保证人的过错程度具体进行酌定。就本案而言，郑某乙、景某某对主合同未尽审查义务，主观上放任了主合同的签订，客观上对主合同的成立也起到了促成作用，具有过错，但其过错相较出借人和借款人较小，故酌情判定其二人承担郑某甲不能清偿部分债务四分之一的赔偿责任，其向原告承担赔偿责任后，可以向郑某甲追偿。

此外，需要说明的是，过错保证人的责任承担在三分之一以下进行酌定是法官自由裁量的体现，实务操作中应当结合保证合同成立的过错，合同的金额，保证人的人数、保证人的过错程度等进行综合认定，以实现各方利益的平衡。

编写人：浙江省宁波市北仑区人民法院 刘叶思

行政机关在执法办案过程中组织形成的鉴定结论， 在民事诉讼案件中的司法认定

—— 甲建设公司诉乙设备公司分期付款买卖合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

山东省济宁市中级人民法院(2023)鲁08民终3304号民事判决书

2. 案由：分期付款买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):甲建设公司

被告(上诉人):乙设备公司

【基本案情】

2020年6月,甲建设公司(需方、甲方)与乙设备公司(供方、乙方)签订《低压母线采购合同》,约定:甲方向乙方采购物资,工程地点:某医院 工地;合同暂定金额4904861元。合同还对《采购清单》、质量标准和技术要求、数量和质量验收、双方责任与义务、违约责任等予以约定。合同签订后,双方相互履行了交货和付款义务。甲建设公司累计向乙设备公司支付货款 4651143.97元。

涉案产品投入使用后,于2021年1月后设备出现击穿、短路等事故。于7月11日多次出现强电间插接箱打火现象,造成插接箱烧坏,造成长时间停电。因产品质量问题,双方当事人经协商,同意共同对涉案产品进行试验检验。乙设备公司于2021年8月12日出具《产品委托说明》,并派遣公司质量管理部部长作为其现场联络员,负责处理相关对接事宜。随后,双方工作人员及监理单位对涉案产品进行取样,并用封条进行了封存。监理徐某在见证人员处签字确认并加盖监理部印鉴。2021年8月17日,甲建设公司同意案涉建设单位济宁某医院项目管理有限公司(以下简称医院项目公司)委托某省产品质量检验研究院(以下简称某省质检院)对取样母线槽的产品质量进行检验,检验结果:电气间隙和爬电距离、短路耐受强度不合格,其他项目合格。

2021年9月16日，医院项目公司向某设计研究院有限公司发出《关于某 医院一期建设工程项目母线更改的通知》，主要内容为：
……经公司研究决定， 将目前使用的母线和插接箱全部更换，请贵院根据项目实际情况出具母线更改 变更单。甲建设公司向乙设备公司发出《告知函》，载明：因涉案产品出现质 量问题，需要拆除，要求被告派技术人员到现场。乙设备公司出具《回复函》， 认为公司提供的产品为合格产品，不认可检验结论，不认可产品质量问题，拆

卸行为系单方行为，不干涉也不承担责任。2021年12月10日，某公证处对甲建设公司拆卸涉案产品进行了现场拍照、摄像，并作出《公证书》。2021年5月10日，甲建设公司与某工程公司签订《某医院一期建设项目部分智能化管材、高低压变配电桥架的施工合同补充协议2》主要涉及密集母排的运维工程。

2021年11月8日，甲建设公司向济宁某省级旅游度假区市场监督管理局（以下简称某市场管理局）递交《举报信》，举报乙设备公司生产销售的母线槽等设备不合格。某市场管理局于2021年11月25日立案，并委托某市产品质量检验研究院（以下简称某市质检院）对案涉母线槽（规格型号：NHMC-1250A/5P、SCC-E-1600A/5P）的布线、操作性能和功能、成套设备的防护等级、短路耐受强度等进行检验。某市质检院于2022年11月7日签发《检验报告》，检验结果为：成套设备的防护等级不合格，短路耐受强度不合格。

【案件焦点】

1. 讼争的产品母线槽是否存在质量问题；2. 双方当事人签订的《低压母线采购合同》是否应予解除；3. 乙设备公司是否应当赔偿甲建设公司损失，数额如何认定。

【法院裁判要旨】

山东省济宁市高新区人民法院经审理认为：原告购买被告的母线槽等产品，在产品投入使用后，出现设备击穿、短路等事故，并出现强电间插接箱打火现象，插接箱被烧坏，造成使用单位长时间停电。后，双方及监理单位共同对涉案产品取样封存，甲建设公司授权建设方委托某省质检院对涉案产品进行检验，检验结果为：电气间隙和爬电距离、短路耐受强度不合格。后，甲建设公司向某市场管理局递交《举报信》。某市场管理局立案后，依法委托某市质检院对涉案母线槽产品质量进行检验，检验结果为：成套设备的防护等级不合格，短

路耐受强度不合格。上述检验报告能够证实，被告制造、销售的上述母线槽产品存在质量问题。因被告的产品存在质量问题，继续使用该产品已不能使

原告实现合同目的，原告要求解除双方所签订的《低压母线采购合同》，应予支持。

因被告销售的产品存在质量问题，给原告造成损失，原告有权要求被告赔偿。赔偿的项目主要包括两部分：一是因双方的合同已经解除，故被告应向原告退还货款4651143.97元。二是为保障市立医院安全运行，原告与某工程公司签订运维协议，对案涉工程的配电室及所有密集母排线路进行运维、抢修，产生运维人工费用、抢修费、代购材料费用共计2519487.59元，后期对案涉母线进行了拆除更换，产生费用1904909.7元，加之母线检测、鉴定费、公证费，原告的实际损失共计9153044.26元。

山东省济宁市高新区人民法院依照《中华人民共和国民法典》的规定，判决如下：

一、解除原告甲建设公司与被告乙设备公司签订的《低压母线采购合同》；

二、被告乙设备公司向原告甲建设公司退还货款4651143.97元，并赔偿损失4501900.29元；

三、原告甲建设公司向被告乙设备公司退还所采购的母线槽等产品。以上二、三项，限被告乙设备公司、甲建设公司于本判决生效之日起15日内履行。

乙设备公司不服一审判决，提起上诉。

山东省济宁市中级人民法院经审理认为：一审判决认定事实清楚，处理结果并无不当。

山东省济宁市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在买卖合同案件中，出卖人交付的标的物的质量直接影响买受人能否实现其订立合同的目的。《中华人民共和国民法典》第六百一十五条规定，出卖人应当按照约定的质量技术要求交付标的物，出卖人提供有关标的物质量说明的，交付标的物应当符合该说明的质量要求。这是买卖合同出卖人应当担负的主要

义务。本案双方买卖的是母线槽，对于母线槽的标准在合同中有明确的约定，应当符合相应的国家标准。随着科学技术的极速发展、社会化大生产大分工的不断衍生，社会生活中出现的难以为公众所掌握的专门性问题越来越多，这些专门性问题有赖于极高的专业素养才能形成较为全面、正确的认知。审判实践中，对于特定物品质量是否符合合同约定，一般通过司法鉴定的方式来认定。本案的特别之处在于在双方对货物质量发生争议后，甲建设公司向相关的市场监管部门举报乙设备公司的产品存在质量问题，市场监管部门立案后，对涉案的产品质量组织了鉴定，该鉴定结论的效力如何认定，具体从以下几个方面进行考量。

一、行政机关在执法办案过程中组织鉴定，形成的鉴定结论属于哪种证据

司法鉴定是指“在诉讼过程中，对于案件中的某些专门性问题，按诉讼法的规定，经当事人的申请，司法机关决定，或司法机关依职权主动决定启动，指派、聘请具有专门知识的鉴定人，运用科学技术手段，对专门性问题作出判断结论的一种核实证据的活动”。简单地说，司法鉴定就是侦查、起诉、审判等诉讼活动中依法进行的鉴定。司法鉴定出具的鉴定意见作为三大诉讼中的法定证据种类之一，其本身具有科学可靠性，被理论界推崇为科学的“证据之王”，其对解决案件中的专门性问题、辅助法官办案上具有不可替代的作用。

我国三大诉讼法上所称的鉴定，指的是司法鉴定，所称的鉴定意见，也是特指由人民法院对外委托启动鉴定得出的意见，而对于当事人个人委托或者行政机关在执法办案过程中组织鉴定形成的鉴定意见没有纳入其中。行政机关在执法办案过程中组织鉴定形成的鉴定意见，在《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条中有明确规定，人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供证据。行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料，在刑事诉讼中可以作为证据使用。但在民事诉讼法中没有类似规定，但新修改的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四十一条规定：“对于一

方当事人就专门性问题自行委托有关机构或者人员出具的意见，另一方当事人有证据或理由足以反驳并申请鉴定的，人民法院应予准许。”从条文规定可以体会出，当事人有自行委托专业机构出具专业意见的权利，对当事人自行委托所谓“鉴定”形成的意见，允许对方反驳，当反驳的证据和理由充分时，另一方当事人还可以申请鉴定。

行政主管部门依照法律、行政法规和规章授权，对相关的专门性问题进行认定过程中所作的鉴定，虽然并非民事诉讼法八种法定证据类型的鉴定意见，也未按照民事诉讼法法定程序进行鉴定人选任、鉴定材料质证与认证等，但由于其行政处理的法定性和行政程序的严谨性，对于相关意见或结论因系有关单位依照管理职权所作出，可以作为书证对待。

二、综合合同标的、合同履行情况，严格审查行政机关执法过程中形成鉴定意见的效力

1. 合同标的物的质量审查。买卖合同标的物的质量一般分为外观质量和内在质量。有的标的物能够直接从外观、品种、型号、规格上识别，是否存在质量问题或质量瑕疵。有的标的物只能从内在质量上衡量是否符合合同约定或法律规定的标准。标的物的内在质量，一般需要买受人在通过检验或使用过程中才能发现。本案的标的物是母线槽，外观上无法识别质量是否符合约定，但在使用过程中，涉案的母线槽在医院运行后，多次出现打火、出现设备击穿、短路等事故，并出现强电间插接箱打火现象，造成插接箱烧坏，以致使用单位长时间停电。

2. 合同履行情况。合同签订是商业交易和社会合作的基础，是维护各方合法权益的基本手段。通过在合同中明确双方的权利义务，规范交易行为，防范纠纷风险，促进合作共赢。“合同目的是否能实现”是判定法定解除是否需要解除的实质标准。本案中双方签订《低压母线采购合同》，约定甲建设公司向乙设备公司采购一批母线槽，用于案涉的某医院一期建设工程项目上-地下水电系统项目，用于保障医院正常的用电安全。但在设备安装完成，医院运行后，接连出现被击穿、短路等事故，造成使用单位长时间停电，给医院运营带来重

大影响。甲建设公司将相关事故通知乙设备公司，双方协商过程中，乙设备公司于2021年8月12日出具《产品委托说明》，派遣其公司质量管理部部长陈某作为现场联络员，负责处理相关对接事宜。随后，双方工作人员及监理单位对涉案产品进行取样，取样后，用封条进行了封存。

甲建设公司单方将封存样品委托某省质检院对取样母线槽的产品质量进行检验。某省质检院于2021年9月18日出具《检验报告》，检验结果：电气间隙和爬电距离、短路耐受强度不合格，其他项目合格。

2021年11月8日，甲建设公司向某市场管理局递交《举报信》，举报乙设备公司生产销售的母线槽等设备不合格。某市场管理局于2021年11月25日立案。并委托某市质检院对案涉母线槽(规格型号：NHMC-1250A/5P)的布线、操作性能和功能、成套设备的防护等级、短路耐受强度等进行检验。某市质检院于2022年11月7日签发《检验报告》，检验结果为：成套设备的防护等级不合格，短路耐受强度不合格。委托某市质检院对母线槽(规格型号：SCC-E-1600A/5P)的布线、操作性能和功能、成套设备的防护等级、短路耐受强度等进行检验。某市质检院于2022年11月7日签发《检验报告》，检验结果为：成套设备的防护等级不合格，短路耐受强度不合格。

3. 行政主管部门的鉴定程序是否合法。参照司法鉴定所作鉴定意见的程序要求，审查出具鉴定意见的鉴定机构是否具有相应的资格、资质；对鉴定意见所依据的证据材料是否真实可靠。对于鉴定的样品是否属于涉案的产品，是否通知当事人到达现场监督取样。

4. 鉴定意见与案件的其他证据有无矛盾。如果行政主管部门委托的鉴定意见与案件中的其他证据基本一致，并无矛盾之处，则其真实性亦在相当程度上得到了保障。本案中，行政主管部门组织形成的鉴定意见与甲建设公司单方委托的鉴定意见结论一致，与本案中出现短路、打火导致用电事故的客观事实一致。

综合上述因素的考量，一、二审判决均认定了行政主管部门组织鉴定形成的鉴定意见的证据效力，对于乙设备公司要求重新鉴定的申请不予准许，并认

定涉案的产品存在质量问题，导致合同目的不能实现，解除了双方签订的《低压母线采购合同》，并由乙设备公司对甲建设公司的损失进行了赔偿。本案通过对案件整体证据进行全面、客观、综合分析之后，确定了行政主管部门组织鉴定形成鉴定意见的效力，避免了再次启动司法鉴定程序，减少了当事人不必要的诉讼成本，保障了当事人的诉讼权利。

编写人：山东省济宁市中级人民法院 潘玉清

保证合同的保证期间与诉讼时效

—— 某银行支行诉某公司保证合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市密云区人民法院(2023)京0118民初490号民事判决书

2. 案由：保证合同纠纷

3. 当事人

原告：某银行支行

被告：某公司

【基本案情】

2017年12月14日，某银行支行与借款人卢某签订《个人额度借款合同》，卢某于2020年1月9日向某银行支行申请金额1650000元借款，额度存续期最长六年，某公司以《企业保证函》提供连带责任保证担保。其《个人额度借款合同》依法办理了具有强制执行效力的公证，《企业保证函》未办理具有强制执行

效力的公证。之后某银行支行依约发放了贷款，但卢某未能按照约定按时

足额偿还，某银行支行向北京市某公证处申请签发《执行证书》，北京市某公证处审核后签发了编号为(2021)京某执字第×××号的《执行证书》。某银行支行于2021年8月向法院申请执行该执行证书未获清偿，故提起诉讼，请求判决某公司承担保证责任。

【案件焦点】

1. 保证合同是否有效以及法律适用问题；2. 保证合同保证期间的约定对合同履行的影响。

【法院裁判要旨】

北京市密云区人民法院经审理认为：该保证合同于民法典施行前成立，而保证期间约定至主债务履行期限届满之日后两年(2023年1月9日)止，保证合同履行持续至民法典施行后。案涉主债务的违约行为虽在民法典施行前，但某银行支行选择通过申请《执行证书》，向主债务人卢某先行主张债权并要求实现对其房屋的抵押权，后因执行未获清偿于2022年向法院单独起诉保证人某公司要求承担连带保证责任，系在民法典施行后因履行保证合同发生争议引发本案诉讼，按照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条、第二十条规定，本案应适用民法典的规定。

北京市密云区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第三百九十二条、第六百八十一条、第六百八十五条第二款、第六百八十八条、第六百九十一条、第六百九十二条、第七百条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条、第二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第九十五条、第一百四十七条之规定，判决如下：

一、某公司对(2021)京方圆执字第××x号《执行证书》载明的全部债务，包括贷款本金1581993.57元，截至2021年4月14日应支付利息9270.94元，罚息、复利36576.8元，自2021年4月15日起至实际付清全部欠款之日止的罚息、复利(罚息、复利按照《个人额度借款合同》约定的结息方式计收，罚息利率按该合同约定的利率基础上加收50%确定)，以及公证费1582

元，向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京密云区支行承担连带清偿责任，其中利息、罚息、复利合计以不超出年利率24%为限。

二、某公司承担保证责任后，有权向卢某追偿。

【法官后语】

上述案例涉及保证合同同时又提到了保证期间问题，虽未涉及诉讼时效，但作为保证制度中争议较大的期间问题，向来是民法热点话题，保证合同是主债务的从合同，存在主合同诉讼时效、保证期间、保证合同诉讼时效三个期间。我国的保证制度主要是由原《中华人民共和国担保法》（已失效）及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》（以下简称《中华人民共和国担保法解释》）（已失效）规定的，部分条文的不具体、不明晰乃至条文之间存在的矛盾冲突致使理论界和实务界长期存在困惑与质疑，围绕保证期间的性质、保证期间的起算、保证期间与保证合同诉讼时效的关系等关键问题的争议层出不穷。

对保证合同保证期间的研究必然会涉及诉讼时效。而其中对于保证合同诉讼时效的起算时间的争议尤为热烈。《中华人民共和国担保法解释》第三十四条^①规定了一般保证和连带责任保证诉讼时效的起算点。对于连带责任保证的规定似乎没有太多质疑。然而在一般保证中，由于一般保证人先诉抗辩权的存在，“从判决或者仲裁裁决生效之日起”的规定一直为学者们所质疑批驳。

《中华人民共和国担保法》第十七条^②及《中华人民共和国担保法解释》第三十四条，从判决或者仲裁裁决生效之日起到执行完毕之日间存在一个时间

①原《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》（已失效）第三十四条：“一般保证的债权人在保证期间届满前对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，从判决或者仲裁裁决生效之日起，开始计算保证合同的诉讼时效。连带责任保证的债权人在保证期间届满前要求保证人承担保证责任的，从债权人要求保证人承担保证责任之日起，开始计算保证合同的诉讼时效。”

②原《中华人民共和国担保法》第十七条第二款：“一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。”

差。针对这一问题,《中华人民共和国民法典》第六百九十四条^①的规定较好地回应了理论界与实务界的期待。但仍有学者从诉讼时效一般规则适用的角度出发,指出该项规定仍存在与总则规定的龃龉,使得保证合同诉讼时效期间的起算点提前,它直接跳过了保证人拒绝承担保证责任这个时间点提前开始计算^②。

《中华人民共和国民法典》第一百八十八条规定,“诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算”。这一规则适用于保证合同中,由于保证合同中的义务人是明确的即保证人,则保证合同的诉讼时效起算点应为债权人知道或者应当知道对保证人的权利受到损害之日。反观《中华人民共和国民法典》第六百九十四条对于保证合同诉讼时效起算的规定,一般保证中为“保证人拒绝承担保证责任的权利消灭之日”,这里的“保证人拒绝承担保证责任的权利”显然意指一般保证人的先诉抗辩权;连带责任保证中为“债权人请求保证人承担保证责任之日”。这两个时点是否可以理解为“权利受到损害之日”呢?学者指出,这样理解是不妥的。“债权人获得对保证人的保证责任请求权并不当然意味着债权人的利益受到损害,保证人拒绝承担保证责任才会最终导致保证合同的债权人的权利受到损害。”^③因此根据总则中诉讼时效适用的一般规则,一般保证中诉讼时效的起算应当为债权人在保证期间对债务人提起诉讼、申请仲裁并强制执行后,债权人要求保证人承担保证责任而保证人拒绝之日;连带责任保证中应当为保证期间内债权人要求保证人承担保证责任而保证人拒绝之日。从维护时效制度的统一性与合理性上讲,应当依照《中华人民共和国民法典》的相关规定确定保证合同诉讼时效的起算点。^④

编写人:北京市密云区人民法院 王佳

①《中华人民共和国民法典》第六百九十四条:“一般保证的债权人在保证期间届满前对债务人提起诉讼或者申请仲裁的,从保证人拒绝承担保证责任的权利消灭之日起,开始计算保证债务的诉讼时效。连带责任保证的债权人在保证期间届满前请求保证人承担保证责任的,从债权人请求保证人承担保证责任之日起,开始计算保证债务的诉讼时效。”

②参见杨巍:《论保证债务诉讼时效的起算》,载《西南政法大学学报》2023年第5期。

③参见杨巍:《论保证债务诉讼时效的起算》,载《西南政法大学学报》2023年第5期。

④卢瑶:《保证期间与保证合同诉讼时效问题研究》,中国地质大学2019年硕士学位论文,第21页。

三、抵 押

26

抵押权人未在主债权诉讼时效期间 行使抵押权，抵押登记应予解除

——单某诉王某抵押权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

安徽省马鞍山市中级人民法院(2024)皖05民终470号民事判决书

2. 案由：抵押权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 单某

被告(上诉人): 王某

【基本案情】

2014年9月22日，案外人刘某、杨某向王某借款30万元，单某同意用自己位于某小区×栋××室房屋抵押担保；同日，上述三方签订借条一份，载明“今借到王某人民币叁拾万元整。某小区×栋××室贷款抵押。”刘某、杨某作为借款人在借条上签字，单某作为担保人在借条上签字。同时在该借条上，刘某书写已收到借款现金叁拾万元整。当日，单某与王某还签订了名为借款合同，

实为担保合同的协议，内容表述为“因甲方生意周转，资金短缺，现用某小区 31 幢804室房产作为抵押，向乙方借款(人民币)叁拾万元整，借款期限为壹 年(2014年9月22日~2015年9月22日)”。

同年9月24日，单某与王某前往不动产登记中心办理了抵押登记手续。其后刘某归还了部分借款。2018年4月21日，在单某不知情的情况下，王某和 刘某、杨某签订新的借款合同，在该合同中未经单某同意，仍约定以单某房产 作为抵押。2022年，王某向花山区人民法院起诉刘某、杨某和单某，要求单某 承担连带还款的担保责任，花山区人民法院驳回了对单某的起诉；王某上诉至 马鞍山市中级人民法院，亦被驳回上诉。

单某向法院提起诉讼请求：判决解除2014年9月24日王某、单某在马鞍 山市不动产登记中心办理的某小区×栋××室房屋抵押登记，王某对单某上述主 张不同意。

【案件焦点】

法院是否应当判决解除单某与王某于2014年9月24日在不动产登记中心办理的案涉房屋抵押登记。

【法院裁判要旨】

安徽省马鞍山市雨山区人民法院经审理认为：单某与王某于2014年9月22日签订的抵押合同约定了期限，而2018年4月21日，王某和刘某、杨某签订借款合同单某并不知情，单某亦未明确表示同意继续将案涉房产作为2018年4月21日借款合同的抵押物。王某提交的证据材料不足以证实其与单某有口头协议，约定偿还27万元后再解除抵押权。故，法院对单某要求解除2014年9月24日王某、单某在马鞍山市不动产登记中心办理的某小区×栋××室房屋抵押登记之诉请予以支持。

安徽省马鞍山市雨山区人民法院判决如下：

解除王某与单某在马鞍山市不动产登记中心办理的某小区×栋××室房屋抵押登记。

王某不服一审判决，提出上诉。

安徽省马鞍山市中级人民法院经审理认为：单某与王某于2014年9月22日签订的抵押合同，约定刘某、杨某向王某借款30万元，借款期限为一年（2014年9月22日~2015年9月22日），单某以案涉房产为该借款提供担保。

《中华人民共和国民法典》第四百一十九条规定，抵押权应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权；未行使的，人民法院不予保护。王某未在该抵押担保主债权诉讼时效期间行使抵押权，故对其未行使的抵押权不予保护。2018年4月21日，王某和刘某、杨某又签订借款合同，安徽省马鞍山市花山区人民法院已生效的（2022）皖0503民初5528号民事判决认定单某未表示同意继续将案涉房产作为2018年4月21日借款合同的抵押物，单某对该借款合同不承担担保责任。王某主张其与单某有口头协议，约定偿还27万元后再解除抵押权，但其提交的证据材料不足以证实该节主张，不予支持。该案中，单某与王某于2014年9月22日签订抵押合同，在单某所有某小区×栋xx室房屋设立的抵押权，抵押权人王某已经丧失了国家强制力的保障，故基于该抵押权作出的抵押权登记失去了存在的基础，应予以注销，故一审法院判决解除2014年9月24日王某、单某在马鞍山市不动产登记中心办理的某小区×栋×x室房屋抵押登记，具有事实和法律依据，予以支持。

安徽省马鞍山市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

不动产抵押权是保障债权的有效手段，从保全债权的角度看，需要强调抵押权的附随性，即只有经过登记，不动产抵押权才能生效。登记生效主义所带来的是不动产登记的正确和人们对正确登记的信赖，随之产生的是不动产登记的公信力和推定力，以及对交易安全和善意信赖的保护。当抵押权人未在主债权诉讼时效期间行使抵押权，未行使的抵押权，人民法院不予保护时，法院是否应当判决解除抵押登记是本案重点研究的问题。

根据《中华人民共和国民法典》第四百一十九条规定，抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权；未行使的，人民法院不予保护。抵押权是一种物权，但与一般物权的区别在于它是以抵押物的交换价值为权利内容。只要有交换价值的存在，抵押权的效力就及于这种交换价值的替代物上。因此，即使未行使的抵押权人民法院不予保护，但只要抵押权登记继续存在，抵押权登记所生的公示力仍然及于对该抵押物。也就是说，人们基于对登记等公示方式的信赖，就推定不动产登记簿上的权利人是真正的权利人，当人们基于这种信赖与登记权利人发生交易时，即使登记权利人不是真正的权利人，法律上也保护他们这种善意信赖以及物权变动的结果。在此情形下，抵押物上所负担的抵押登记，对原抵押权人来讲，其抵押权已经丧失了国家强制力的保障；对抵押人而言，继续维持抵押登记势必影响抵押物的正常使用和流转，尤其会影响抵押物交换价值的实现，妨害抵押人所有权的行使，继续维持抵押登记的存在，丧失了合法、合理的依据。即使抵押权没有法定的消灭情形，但当抵押权人未在主债权诉讼时效期间行使抵押权时，从物尽其用、节约资源的角度考量，法院应当判决解除抵押登记。

编写人：安徽省马鞍山市中级人民法院 孙怡

抵押权代持的成立应当以担保人明知委托关系存在为前提

——李某1诉姚某、范某抵押权案